

1500706-27.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... autoridade policial toma conhecimento do tráfico, sendo-lhe inerente o dever de investigar.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500706-27.2021.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500706-27.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244257/2021 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 9, 20114701 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 98/21/592 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2244257 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK CORDOVA MONRROY

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

ERICK CORDOVA MONRROY, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, tinha em depósito ou guardava, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (treze tabletes de cocaína, com massa líquida total de 12.050g), que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, além quantia em dinheiro.

A denúncia de fls. 107/108, foi recebida em 04 de novembro de 2021 (fls. 178/179).

O réu foi citado (fls. 167), apresentando defesa (fls. 162/163).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 207/208).

Em seus memoriais (fls. 218/231), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

O Doutor Defensor do réu (fls. 292/299), requereu a absolvição por falta de provas, pela existência da excludente de antijuridicidade de coação irresistível e por fim, a aplicação do tráfico privilegiado, com fixação de regime mais brando.

Foram juntados os laudos de fls. 270/275 e 356/358, além do link de acesso as mídias (fls. 366). E aportou aos autos a resposta do ofício (fls. 334). As partes manifestaram-se (fls. 377, 370 - Ministério Público, e fls. 375 - defesa).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelos laudos de fls. 95/97.

É notório o perigo à incolumidade pública causado pela droga conhecida como cocaína de alto poder viciante e que causa dependência física e psíquica, demonstrando estar plenamente caracterizada a prática delitiva.

De acordo com a doutrina:

"É tão grave a nocividade dessa droga que, mesmo depois da cura pela desintoxicação, o viciado não se recupera das lesões mais graves do sistema nervoso. Tem estados depressivos e de angústia, alucinações visuais e tácteis, delírios de perseguição e complexo de culpa. Envelhece muito precocemente, e a morte é quase sempre por perturbações cardíacas" (DE FRANÇA, GENIVAL VELOSO. Medicina Legal. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, p.308).

A esse respeito, a matéria publicada no conceituado jornal "Folha de São Paulo"; em 30 de dezembro de 1994:

"Cocaína é maior causa de infarto em jovens

A cocaína é responsável por quase todos os infartos do miocárdio em jovens com menos de 30 anos. A constatação é da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) que lança na próxima semana uma campanha nacional de informação.

O objetivo é esclarecer as pessoas sobre as doenças do coração e o que se deve fazer para evitá-las. Entre os jovens, o uso da cocaína é o que mais preocupa a SBC.

"Eles precisam saber que a cocaína tem efeitos mortais no organismo", diz Claudio Buarque Benchimol, 47, secretário-geral da SBC. "Quase todos os jovens que chegam com infarto nos hospitais fizeram uso de cocaína", afirma.

É o que acontece no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, umas das mais importantes portas de entrada de vítimas de infarto em São Paulo.

O cardiologista Marcello Barduco, do pronto-socorro do Incor, confirma que entre os jovens a causa do infarto está quase sempre associada ao uso de cocaína.

O hospital registra uma média de um a três casos de infartos em jovens por mês. A cada 24 horas, o Incor recebe uma média de cinco vítimas de infarto, idosos na grande maioria.

Não há estudos sobre os riscos nem estatísticas sobre casos de infarto por droga entre jovens. De acordo com Benchimol, o número de mortes do coração provocado por

cocaína pode estar subnotificado por interferência da família. Ou mesmo pela dificuldade em se apontar a droga como causa.

De todo modo, o número de jovens que morrem por infarto é pequeno. Segundo dados da Fundação Seade, apenas 33 jovens entre 15 e 29 anos morreram de infarto do miocárdio na cidade de São Paulo no ano passado. Para se ter uma idéia, nesse mesmo período, 2.298 jovens dessa faixa de idade foram assassinados com armas de fogo e outras armas. Outros 561 morreram no trânsito.

A preocupação da SBC é com o aumento do uso da cocaína registrado nos últimos anos. "O número de usuários dessa droga vem aumentando no mundo todo", diz Benchimol. Pesquisa feita entre estudantes de 1º e 2º graus de dez capitais brasileiras mostra que 1,2% deles já experimentou cocaína. Cinco anos atrás, apenas 0,7% dos estudantes tinham usado a droga uma vez. A pesquisa foi feita pelo Cebrid, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas.

O perigo da cocaína é apenas um dos itens da campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os médicos pretendem informar em linguagem simples como se iniciam as doenças do coração e o que pode agravá-las ou fazer com que regridam.

A hipertensão arterial e o fumo, por exemplo, são fatores de risco para um infarto. Alimentação correta, pouco estresse e exercícios físicos ajudam a manter o coração mais saudável."

E ainda:

"A quantidade necessária para provocar uma overdose varia de uma pessoa para outra, e a dose fatal vai de 0,2 a 1,5 grama de cocaína pura. A possibilidade de overdose, entretanto, é maior quando a droga é injetada diretamente na corrente sanguínea. O efeito da cocaína pode levar a um aumento de excitabilidade, ansiedade, elevação da pressão sanguínea, náusea e até mesmo alucinações.

(...)

A cocaína é a droga que mais rapidamente devasta o usuário. Bastam alguns meses ou mesmo semanas para que ela cause um emagrecimento profundo, insônia, sangramento do nariz e coriza persistente, lesão da mucosa nasal e tecidos nasais, podendo inclusive causar perfuração do septo (12). Doses elevadas consumidas regularmente também causam palidez, suor frio, desmaios, convulsões e parada respiratória". (S.H. Cardoso e R.M.E. Sabbatini; Revista Cérebro & Mente 3(8), jan/mar 1999).

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os Policiais Civis declararam que receberam uma denúncia anônima acerca de uma movimentação atípica em uma casa de um bairro residencial, por um indivíduo estrangeiro, com possível envolvimento do tráfico. Realizaram, então, uma diligência ao local, verificando um veículo prata adentrando a casa, permanecendo por cerca de dez minutos, e após saindo. Narraram que optaram por seguir o veículo, e visualizaram o indiciado adentrando uma chácara, momento em que solicitaram apoio da DISE. Informaram que efetuaram, então, a abordagem, localizando alguns indivíduos na porta da chácara, e indagaram acerca do indivíduo estrangeiro, indicando que o réu estava no interior. Indagado, o réu confirmou que estava no veículo e afirmou que ele foi ameaçado por outros indivíduos, a tomar conta do local. Disseram, ainda, que retornaram a casa e, ante a indicação do réu, na churrasqueira foi localizada uma quantidade de substância entorpecente. E, no interior de tábuas de carnes foi localizada mais drogas. Diligenciaram, também, a residência do réu, onde não foi localizado nada ilícito, apenas roupas. Por fim, não foi verificado o envolvimento das demais pessoas abordadas na chácara.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas (“Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) – Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente – Condenação mantida Penas corretamente fixadas – Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares – Inocorrência – Decisão motivada – Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada uma dos argumentos apresentados – Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida – Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados – (...) – Sentença mantida – Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

APELAÇÃO – tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico obedecido, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Impetração visando a absolvição do apelante por fragilidade probatória, com base na negativa de autoria e nas contradições existentes nas versões dos policiais – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade comprovadas – Negativa de autoria isolada nos autos – Depoimentos dos policiais com pequena contradição referente ao papel do apelante no tráfico que não afeta a decisão condenatória – Testemunhas de defesa que apresentaram declarações com detalhes sequer mencionados pelo apelante, em seu interrogatório – RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Apelação Criminal 0004594-74.2014.8.26.0161; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2016; Data de Registro: 29/08/2016)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Inclusive, julgando Apelação Criminal oriunda deste juízo, assim decidiu a 14ª Câmara do 7º Grupo da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Ressalte-se que, eventuais discrepâncias entre os depoimentos não geram insegurança acerca dos fatos, pois oriundas das imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada, sendo, sim, importante, verificar se, embora divergentes em detalhes mínimos, concordam os testemunhos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias mais decisivas dos fatos” (Apelação Criminal nº 00976517.3/3-0000-000, Rel. DES. FERNANDO MATALLO, 24.05.2007).

Em que pesem as alegações da defesa acerca da entrada ilegal, a alegação deve ser afastada. Com efeito, já é pacífico na jurisprudência a possibilidade do policial militar ou guarda municipal realizar a prisão, porque nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode realizar prisão em flagrante. Além disso, o direito à inviolabilidade do domicílio possui exceção na própria constituição, no caso de flagrante delito.

Tendo em vista que o delito de tráfico de entorpecentes é delito permanente, cuja consumação se protraí no tempo, não há nenhuma ilegalidade na atitude dos policiais.

À respeito da natureza permanente do delito, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "Dispõe o artigo 303 que, nas infrações, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, o que, na verdade, é despidiendo, já que, nessa espécie de ilícito, a consumação se prolonga no tempo, dependendo da vontade do

agente, como ocorre nos crimes de seqüestro (art. 148, do CP), de extorsão mediante seqüestro (art.

149, do CP), nos crimes cuja conduta é 'guardar consigo \ 'ter em depósito', 'transportar' etc. Nessas hipóteses o crime está sendo cometido durante o tempo da consumação, havendo, pois, caso típico de flagrância. O dispositivo, porém, evita qualquer interpretação em contrário, cumprindo ressaltar que é ele repetido no Código de Processo Penal italiano de 1988 (art. 328,2). Não se contesta a situação de flagrância nessas hipóteses, inclusive quanto ao crime de quadrilha, em ação de transporte de coisas subtraídas, de receptação dolosa por ocultação, de depósito de substância entorpecente etc.

Evidentemente, tratando-se de prisão em flagrante, mesmo nas hipóteses em que se deva invadir casa alheia, não se exige mandado judicial (g.n. –Processo Penal - 3a ed. - Ed. Atlas - 1994 - pág. 360).

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO. Direito de recorrer em liberdade. Perda superveniente do objeto. Prova ilícita. Inexistência. Situação flagrancial que autoriza o ingresso na residência independentemente de ordem judicial. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Tráfico ilícito de entorpecentes. Insuficiência de provas. Inocorrência. Circunstâncias que evidenciam que a droga se destinava à mercancia. Palavra dos agentes policiais que merece crédito. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Pena privativa de liberdade. Majoração da pena-base de rigor. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Pena intermediária. Atenuante genérica da confissão. Cabimento. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Regime inicial de cumprimento da pena. Regime fechado que se mostra mais adequado ante as circunstâncias do caso concreto, a despeito do teor do art. 387, §2º, do CPP. Pena restritiva de direitos. Não cabimento. Manutenção da prisão. Persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva agregada à possibilidade de execução provisória da pena após a prolação do acórdão condenatório. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000004-65.2015.8.26.0631; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Amparo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/11/2016; Data de Registro: 29/11/2016)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que, após chegada ao local para averiguação de "denúncia anônima" recebida acerca da chegada de um carregamento de drogas na residência, o corréu ALEX percebeu a presença da guarnição e correu para dentro do imóvel, momento em que os policiais decidiram ingressar na residência e flagraram os corréus VILSON e ARIZON descarregando tabletes de pasta-base de cocaína de uma Kombi semidesmontada, tendo o paciente e o corréu OSVALDO sido detidos no interior do domicílio. Realizada as buscas pessoais, veiculares e as demais diligências, a atividade policial logrou em apreender 107 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 95,245Kg. De sorte que eram fundadas as razões para a atuação policial. Desse modo, na presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal, não há como acolher a alegada ilicitude da prova para absolver o paciente pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 569.437/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,

QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)

Recurso de habeas corpus. Prisão em flagrante. Guarda municipal. Apreensão de coisas. Legalidade. Delito permanente. – “A guarda municipal, a teor do dispositivo, § 8º do artigo 144 da CF, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do Município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do CPP. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta – também – a apreensão de coisas, objeto do crime. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 – modalidade guardar substância entorpecente” (STJ – 6ª T. – RHC 7.916- Rel. Fernando Gonçalves – DJU 09.11.1998; Revista Jurídica 255/126; JSTJ e TRF-LEX 115/303).

“Não há ilegalidade na prisão, vez que realizada em flagrante delito, nos termos do artigo 302, do Código de Processo Penal, por guardas municipais, ainda que não possuam a função de preservar a segurança pública (destinou-se-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais artigo 144, § 8º, da Constituição Federal). Ademais, como é cediço, qualquer do povo poderá render quem quer que seja encontrado em flagrante delito (artigo 301, do Código de Processo Penal), constituindo notório contrassenso admitir que guardas municipais não possam proceder da mesma maneira legal.(TJSP – 14ª Câmara, Apelação nº 0017308-46.2010.8.26.0019, Relator Des. Marco de Lorenzi, j. 01.03.2012)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase préprocessual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada. (STJ, 5ª Turma, HC 129932/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 15.12.2009).

Ainda, não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dos policiais tem o mesmo valor que o de qualquer outra testemunha, ainda mais quando a mera alegação de imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

Tráfico de entorpecentes – Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 21,5 gramas de cocaína, em pó – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes – Dolo de traficar – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for

observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes. (TJSP; Apelação Criminal 0003382-85.2013.8.26.0538; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "os dados acidentais e os contornos acessórios do fato justificam o juízo condenatório, pois firmada a evidência de não corresponder a ação do réu, por qualquer argumento, ao uso de entorpecente. Assim, entendo que não deve ser aplicada a desclassificação ao caso em epígrafe, para que não seja violado aquilo que se conhece por razoável, na medida em que, na espécie, não se cogita do imponderável sobre a existência do fato e da autoria, mas, ao contrário, se denota, de forma efetiva, que a conduta do réu deve ser classificada como incluída no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006". Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela desclassificação da conduta do agravante para uso de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Admissibilidade - Relato que não deixa dúvida alguma do encontro de maconha em poder do agente - Condenação mantida O agente da polícia serve como testemunha, tal qual qualquer outra pessoa, até porque ele é auxiliar da Justiça criminal e não é de supor-se que se transforme em parte, que compareça a juízo para perseguir sistematicamente pessoas inocentes, para as quais criam crimes

inexistentes. (Relator: Djalma Lofrano - Apelação Criminal n. 159.299-3 - Botucatu - 18.08.94)

Assim, diversamente do sustentado, nenhum abuso ocorreu na diligência policial, desencadeada por denúncia anônima. Tratando-se "de crime permanente, a ensejar sempre prisão em flagrante, não há que se questionar sobre a preexistência, nulidade ou descumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, porque a inviolabilidade domiciliar é princípio que não se compadece, em termos infracionais, com o desvio de finalidade da função da própria casa, conforme se infere do disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal" (JCAT 75/590).

No mais, não há qualquer irregularidade pelo fato de investigação se ter iniciado por denúncia anônima. É irrelevante o meio pelo qual autoridade policial toma conhecimento do tráfico, sendo-lhe inerente o dever de investigar. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que, após chegada ao local para averiguação de "denúncia anônima" recebida acerca da chegada de um carregamento de drogas na residência, o corréu ALEX percebeu a presença da guarnição e corréu para dentro do imóvel, momento em que os policiais decidiram ingressar na residência e flagraram os corréus VILSON e ARIZON descarregando tabletes de pasta-base de cocaína de uma Kombi semidesmontada, tendo o paciente e o corréu OSVALDO sido detidos no interior do domicílio. Realizada as buscas pessoais, veiculares e as demais diligências, a atividade policial logrou em apreender 107 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 95,245Kg. De sorte que eram fundadas as razões para a atuação policial. Desse modo, na presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal, não há como acolher a alegada ilicitude da prova para absolver o paciente pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 569.437/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)

A grande quantidade de tóxico apreendida, bem como sua forma de acondicionamento, evidencia a destinação de tráfico.

É certo que a simples apreensão de grande quantidade que não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, a quantidade expressiva, somada a forma de acondicionamento da substância entorpecente, é forte indício do comércio ilícito, que aliada às demais circunstâncias servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório.

As testemunhas de defesa Marcos e Tamires, nada relataram acerca dos fatos, apenas informaram as características pessoais e profissionais do réu. Confirmaram, ainda, que o réu e a esposa procediam a venda de roupas no Brás/SP.

Ainda, a testemunha de defesa Andrea, ouvida com auxílio de tradutor, informou que é esposa do réu, e vieram a cerca de dois anos para o Brasil, para trabalhar no comércio de roupas. Confirmou que o réu tem três filhos, com 22, 20 e 12 anos, e vivem na Bolívia. Informou que o réu enviava dinheiro para ajudar os filhos na

Bolívia. Negou que o réu estivesse envolvido com o tráfico de drogas no Brasil ou na Bolívia. Disse que não tem conhecimento acerca dos fatos, sendo que era a primeira vez que foram na chácara. Por fim, na casa pensavam em passar o final de semana, pois tinha piscina. E, na chácara, não sabe a razão de ir, apenas foi acompanhar.

O acusado, ouvido com auxílio de tradutor, negou a prática do delito, alegando que apenas tomava conta da casa, e foi contratado por bolivianos, não tendo conhecimento se eram os proprietários. Disse que não recebia pagamento pelo trabalho de caseiro. Declarou que recebia ameaças, inclusive em face da família que vive na Bolívia, se não tomasse conta da casa. Negou que tivesse indicado aos policiais onde estava localizada a droga na churrasqueira e na tábua de carne, tendo apenas aberto a casa. Informou que ia a casa todas as noites, e deveria entrar e verificar se ela estava em ordem, fechar portas e apagar luzes, não sabendo quem frequentava a casa durante o dia. No dia dos fatos, passou na casa, e depois dirigiu-se a chácara.

No entanto, a versão pueril do réu em juízo, restou isolada no conjunto probatório.

Em que pesem as declarações da defesa acerca da alegada coação (ameaça - inclusive da família) para a guarda da droga, restou improvada. E, como é sabido, o ônus de provar incumbe a quem faz a alegação.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO CONDENATÓRIO - VIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS - PROVA FIRME E CONSISTENTE DEMONSTRANDO A GUARDA DO ENTORPECENTE PELO RÉU - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA DEFESA - RECURSO PROVIDO - DE OFÍCIO - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964246.

- Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o réu como autor do crime de tráfico de drogas, imperiosa a reforma da sentença para condená-lo.

- Para a caracterização do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, crime de ação múltipla, basta que o agente guarde drogas, não exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.

- Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.

- Impossível a absolvição do agente que alega ter praticado conduta antijurídica sob coação moral irresistível se não comprovada a alegada excludente de culpabilidade, sendo certo que, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus incumbirá à Defesa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.13.083392-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/0018, publicação da súmula em 22/01/2019)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude das substâncias apreendidas (maconha e cocaína. Policiais civis, depois de informados por um usuário de drogas acerca da guarda de entorpecentes pelo réu na própria casa, identificaram o imóvel do increpado, foram atendidos por ele e, em busca domiciliar, encontraram sobre a cama um pacote contendo cocaína (970,3g) e diversas porções de maconha (628,6g), cigarros, além de uma balança de precisão e diversos saquinhos plásticos vazios, ocasião em que o réu confessou informalmente o tráfico de drogas e revelou que tinha por função fracionar o entorpecente, o qual pertencia ao traficante Bruno. Testemunhas de defesa que não esclareceram os fatos. Apelante, silente na fase policial, asseverou em juízo que guardara o entorpecente porque fora ameaçado de morte pelo traficante proprietário da droga, alegando, pois, coação moral

irresistível. Defesa não se desincumbiu do ônus da prova da excludente de culpabilidade. Negativa e versão judiciais isoladas nos autos. Condenação mantida. (TJSP; Apelação Criminal 1511522-47.2020.8.26.0228; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/02/2021; Data de Registro: 27/02/2021)

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Crack e maconha. Autoria e materialidade do crime bem demonstradas. Apreensão de relevante quantidade de entorpecentes na casa do réu, que confessou em Juízo guardá-los em favor de terceiro. Coação moral irresistível não configurada. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Base que deve ser fixada no mínimo. Subsequente incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Suficiência dos requisitos explícitos no dispositivo. Comprovada a primariedade e os bons antecedentes é descabido negar o desconto de penas proporcionado pelo dispositivo em questão apenas presumindo a dedicação do acusado às atividades ou grupos criminosos. Causa de diminuição de pena reconhecida. Regime fechado mantido. Provimento parcial do recurso. (TJSP; Apelação Criminal 0005229-87.2016.8.26.0451; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/06/2017; Data de Registro: 29/06/2017)

Por fim, o fato do réu já possuir processos por delito de igual natureza em outro País (resposta de fls. 334), o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, é indício que fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais: PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o *fumus comissi delicti*, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o *periculum libertatis*, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

Desta forma, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, os objetos e/ou o valor em dinheiro de origem não elucidada permitem a segura conclusão de que o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico, razão pela qual é impossível,

ainda, a desclassificação para o consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório. Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Incabível. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de drogas - A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Inadequada. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos representam perigo maior, atingindo incontáveis usuários, além de apresentarem alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de entorpecentes na rua - Ademais, as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação habitual do apelante à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, não se tratando de mero traficante eventual, que, por descuido, envolveu-se com a traficância momentaneamente - (...) - Pena e regime mantidos Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº 0002456-25.2017.8.26.0616, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Presença de indícios tipificadores do delito - Apreensão de grande quantidade de entorpecente - Excessivo poder de compra que não se adequa à condição simples do réu - Aplicação dos artigos 12 e 37 da lei 6368/76 - Recurso não provido. (Relator: Gentil Leite - Apelação Criminal n. 161.748-3 - Campinas - 01.09.94)

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Ré surpreendida na posse expressiva quantidade de maconha e uma porção de cocaína - Quantidade e natureza da droga que evidencia o objetivo de mercancia - Recurso não provido. (Relator: Segurado Braz - Apelação Criminal n. 161.094-3 - São José do Rio Preto - 16.05.94)

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista que a extrema nocividade da cocaína, exigindo especial rigor no combate ao seu tráfico, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, pela necessidade de impor ao traficante pena de severidade correspondente ao elevado risco que o comércio dessa nefanda substância acarreta à saúde pública.

O réu agiu reprovadamente com vontade livre e consciente, dirigida à prática de condutas que representam tráfico de cocaína, droga especialmente perigosa, colocando em grave perigo a saúde pública, acrescendo como circunstância a quantidade expressiva da droga, tendo como motivo o propósito de locupletamento, vale dizer, ganho fácil e espúrio.

Com efeito, segundo Damásio:

“O novo sistema penal prevê duas fases na aplicação da pena. Num primeiro momento, com fundamento no princípio da pena retributiva, fixa sua qualidade e quantidade, elaborando um juízo sobre o passado (juízo de culpabilidade), atendendo à gravidade objetiva do delito, antecedentes e personalidade do agente, sua conduta social anterior, motivos determinantes do fato e suas conseqüências.” (Damásio Evangelista de Jesus, “Direito Penal”, Parte Geral, 1 volume, 19ª Edição, Saraiva, 1995, p. 509)

Havendo uma graduação de penas, é evidente que a pena mínima, deve ser aplicada por exemplo àqueles que comercializam pequena quantidade de "maconha", tóxico muito menos grave e nocivo que a cocaína, que envolve interesses de grupos altamente perigosos, que para a sua difusão e fabricação se organizam freqüentemente em quadrilhas, patrocinando "chacinas", segundo diariamente noticiado nos jornais. Destarte é indiscutível que a cocaína apresenta um perigo muito maior, uma maior potencialidade de dano social. Como dito acima, a cocaína freqüentemente leva à morte, além de ser porta para outros tipos de tóxicos mais graves, como a heroína, por exemplo.

A propósito, julgando feito em trâmite por este juízo, assim decidiu a Egrégia 11ª Câmara Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo relator foi o Desembargador Di Rissio Barbosa, do seguinte teor: Comércio Clandestino de entorpecente. Pena. Exacerbação decorrente da natureza da droga, "crack", cujos efeitos são mais graves que outras drogas. Não é só admissível a exacerbação, como também recomendável por diferenciar situações díspares. (Apelação 455.718.3/1-00, 8 de junho de 2005).

Da brilhante decisão, destaco o seguinte trecho:

"...o aumento decorrente do tipo de droga, de extrema conseqüência, foi adoção que todos os Magistrados deveriam ter em mente ao calcular a pena; realmente, não se pode deferir a mesma repressão aos que se envolvem com drogas consideradas leves, pelas conseqüências que determinam, e outras consideradas pesadas, aqui com maior desprezo ao infeliz semelhante usuário".

Além disso, existe o imperativo legal do artigo 42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual a quantidade e natureza da droga devem preponderar sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal no momento de fixação da pena base. Segundo o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA NATUREZA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1,956 KG DE COCAÍNA. LEGALIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO ÓRGÃO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019) e que "[i]nexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio [...]" (HC 448.085/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) 2. No caso, a majoração da pena-base em 2 (dois) anos está suficientemente fundamentada, pois as vetoriais previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 foram sopesadas negativamente em razão da apreensão de 1,956 kg (um quilograma e novecentos e cinquenta e seis gramas) de "cocaína". 3. O quantum de majoração adotado não se mostra desarrazoado ou desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão), bem como a natureza e elevada quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 536.692/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. MODIFICAÇÃO DE REGIME. PLEITO PREJUDICADO, ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. ADEMAIS, PENA SUPERIOR A 7 ANOS E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cediço que, quanto à exasperação da pena-base no crime de tráfico, o juiz deve considerar, com

preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, verifico que a pena-base foi exasperada em razão da variedade/quantidade das drogas (48,759kg de cocaína e 1,011kg de crack), fundamentos idôneos para